

1500215-09.2021.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Mailon, as drogas apreendidas para fins de tráfico. III - Da associação entre MAILON e ALESSANDRO, gerentes de pontos de tráfico vizinhos que atuavam em colaboração: Continuando a análise das conversas pelo aplicativo "Whatsapp" extraídas do aparelho celular de MAILON, foi também possível notar que este dialogou com a pessoa registrada em sua agenda de contatos como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500215-09.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500215-09.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA e outros

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no topo dos artigos 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, de mailon henrique candido presunto e alessandro cristiano silva, também já qualificados nos autos, como incursos (MAILON por duas vezes) no topo do artigo 35 da Lei 11.343/06, em concurso material, afirmando que desde data incerta, porém até o dia 22 de setembro de 2020, Jeferson e Mailon associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas; sendo que no dia 22 de setembro de 2020, por volta de 16h, na "Biqueira dos Mumbuca", situada na rua João Simão, Bairro Cristo Redentor, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, Jeferson agindo na forma da associação criminosa mencionada, forneceu e expôs à venda, mediante o associado Mailon, 25 porções de "cocaína" com peso bruto de 46,0 gramas e 08 porções de "maconha" com peso bruto de 12,0 gramas; desde data incerta, porém até o dia 22 de setembro de 2020, Mailon e Alessandro, ambos gerentes de ponto de venda de entorpecentes, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, mas em cooperação, o crime de tráfico de drogas.

Segundo narrou denúncia:

"Os denunciados JEFERSON, vulgo "Gordão", e MAILON PRESUNTO, desde data incerta,

porém até o dia 22 de setembro de 2020, data da prisão em flagrante deste no ponto de venda de drogas conhecido como “Biqueira dos Mumbuca”, associaram-se, de forma estável e permanente, a um coordenado esquema para a prática do tráfico de drogas no citado local, situado no Bairro Cristo Redentor, notório e incessante ponto de traficância na comarca, alvo de inúmeras apreensões e prisões pelas polícias Civil e Militar (cf. relatório policial às fls. 19/237 e boletins de ocorrência às fls. 252/262).

Para tanto, o denunciado JEFERSON (“Gordão”) atuava como “proprietário” do ponto de venda, administrando-o financeira e organizacionalmente, garantindo o abastecimento das drogas, enquanto MAILON PRESUNTO exercia a função de “gerente”, ou seja, realizava a arrecadação dos valores, divisão de horários, venda direta e contratação de outros vendedores que lá se revezaram com ele.

O desmantelamento da associação em questão, com a identificação do “dono” da “Biqueira dos Mumbuca”, teve início com a prisão em flagrante de MAILON PRESUNTO no dia 22 de setembro de 2020 no referido ponto de tráfico (autos nº 1500768-90.2020.8.26.0472 – doc. 01 em anexo), ocasião em que foi apreendido seu aparelho celular e, mediante autorização judicial para análise policial e degravação, bem como compartilhamento nestes autos (fls. 06/18), obteve-se material de interesse, apontando a propriedade da “biqueira” atribuída a JEFERSON e sua gerência por MAILON (relatório às fls. 19/237). Das mensagens de troca “Whatsapp”, foi possível concluir que MAILON dialogou com a pessoa registrada em sua agenda de contatos como “Primo”, sendo que os diálogos denotam claramente que ambos tratam, em sua maioria, sobre a mercancia de drogas na “Biqueira dos Mumbuca” e indicam claramente que “Primo” figura como “dono” do ponto de venda, o qual fica, inclusive, a poucos metros de distância da residência de MAILON, que a ele se reporta prestando contas.

Em apertada síntese do apurado no minucioso relatório policial de fls. 19/237 e com alguns destaques abaixo, vê-se que “Primo” dá ordens para MAILON não deixar o “bagulho” (drogas) acabar; que quando as drogas estiverem prestes a acabar é para avisá-lo que ele irá ordenar para que reponham as quantidades vendidas; que MAILON não deixe ninguém mexer na “caixinha” (dinheiro); cobra mais disposição para a venda das drogas; estabelece metas de vendas até determinado horário etc.

É fácil perceber que o indivíduo registrado na agenda do celular de MAILON como “Primo” é o denunciado JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, vulgo “Gordão”, pois no decorrer dos diálogos aquele sempre chama “Primo” pelo prenome “Jeferson”, além de, em dados momentos, se referir a ele também como “Gordão”.

Além disso, o policial civil Brizano A. Silva, responsável pela degravação do conteúdo do aparelho, consignou no relatório (à fl. 23) que, ao ouvir diálogos entre MAILON e “Primo”, de imediato foi possível reconhecer que a voz deste era de JEFERSON, pois é indivíduo já conhecido dos meios policiais e vem ao encontro do apurado pelo setor de inteligência da Delegacia de Porto Ferreira, apontando ser ele o “dono” da “Biqueira dos Mumbuca”, sendo que ele também reside há poucos metros do local onde instalada.

Também foi consignado no relatório que MAILON e JEFERSON possuem o mesmo endereço, cujo terreno possui várias pequenas casas, conhecido como “Mumbucas”, nome atribuído ao patriarca da família, o qual era conhecido como “Mumbuca”.

Aliás, acredita-se que, por este motivo, MAILON atribuiu a JEFERSON o nome “Primo” em sua agenda de contatos, uma vez que é possível que tenham algum parentesco um pouco mais distante, além de servir a alcunha, por óbvio, para dificultar a identificação policial no caso de apreensão e análise do aparelho.

A seguir, apresento os destaques de algumas das conversas entre os denunciados MAILON e JEFERSON que demonstram a organização e funcionamento da associação entre eles, registrando que a íntegra dos diálogos encontra-se no relatório de fls. 19/237. Importante consignar, ainda, que tais mensagens foram localizadas e/ou recuperadas pelo policial responsável pela degravação não obstante os esforços dos denunciados em, demonstrando expertise criminoso, tentarem apagar os registros das conversas com conteúdo criminoso conforme se observa ao longo de vários trechos degravados com o seguinte apontamento: Mailon em atitude suspeita, portando uma “pochete”, acessório comumente utilizado pelos traficantes desta comarca para

acionar o dinheiro arrecado e entorpecentes a serem distribuídos e vendidos, razão pela qual foi abordado.

Realizada busca pessoal, os policiais localizaram as porções de drogas acima mencionadas no interior da "pochete", todas fracionadas e prontas para serem comercializadas, bem como a quantia de R\$ 247,40 em notas variadas, produto da traficância. Mailon, que é contumaz violador da norma penal desde quando adolescente, ostentando passagens anteriores pela Fundação Casa pelo tráfico de drogas no mesmo local ou próximo a ele (cf. certidão de antecedentes infracionais em anexo), confessou integralmente a prática do delito tanto na fase policial quanto em juízo, mas sempre sem indicar quem era seu "chefe".

Após instrução processual, Mailon foi condenado em primeira e segunda instâncias como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual agora, com a apuração de quem era seu "chefe", JEFERSON está sendo denunciado por tais fatos, estando a condenação daquele pendente apenas de certidão de trânsito em julgado, já que não houve, no prazo, interposição de recurso pelas partes (cf. documentos em anexo extraídos dos autos nº 1500768- 90.2020.8.26.0472).

Assim, as circunstâncias da prisão em flagrante de Mailon e o desmantelamento da parceria criminosa estabelecida, demonstram, com segurança, que JEFERSON, agindo na forma da associação, forneceu e expôs à venda, mediante o associado Mailon, as drogas apreendidas para fins de tráfico. III - Da associação entre MAILON e ALESSANDRO, gerentes de pontos de tráfico vizinhos que atuavam em colaboração: Continuando a análise das conversas pelo aplicativo "Whatsapp" extraídas do aparelho celular de MAILON, foi também possível notar que este dialogou com a pessoa registrada em sua agenda de contatos como "Cristiani" (ALESSANDRO CRISTIANO), sendo que os diálogos denotam claramente que ambos tratam da mercancia de drogas no Bairro Cristo Redentor, extraíndo-se delas a função de gerência que ambos exerciam em seus respectivos pontos de venda ("Biqueira dos Mumbuca" e "Biqueira da Nove") e, ainda, o auxílio que um prestava ao outro na traficância, inclusive com o aviso da presença policial na região, realização de tratativa compartilhada com outros donos de "biqueiras" vizinhas e vendedores e, ainda, a indicação do horário de encerramento das atividades criminosas.

Em apertada síntese do apurado no relatório policial de fls. 19/237 e com alguns destaques abaixo, vê-se que "Cristiani" fala pra MAILON avisar "Neginho" (pessoa não identificada) que ele está com o "barato" (drogas); comenta com MAILON que foi buscar droga no fornecedor e veio "umas cento e poucas gramas a mais" do que o combinado, sendo que essa quantia é "presa" (espécie de cortesia);

"Cristiani"(ALESSANDRO) se auto intitula "gerente" de biqueira; diz para MAILON descer na sua "loja" (biqueira); que vai passar para o próximo assumir a biqueira; que vai fechar o expediente na biqueira porque tá passando muita viatura policial; que vai fechar o expediente "onze e pouco", pois o seu pessoal já está passando mal lá (ficaram o dia todo vendendo drogas e estão cansados) etc.

E foi fácil identificar que o indivíduo cadastrado na agenda do celular de MAILON como "Cristiani" era o denunciado ALESSANDRO CRISTIANO SILVA, pois além da proximidade do segundo nome, a fotografia deste estava visível no aplicativo de mensagens, além de também ter tido sua voz nos arquivos de áudio reconhecida do policial civil subscritor do relatório.

A seguir, apresento os destaques de algumas das conversas entre os denunciados MAILON e ALESSANDRO que demonstram a cooperação e associação entre eles, registrando que a íntegra dos diálogos encontra-se no relatório de fls. 19/237.

Não foi possível identificar nos levantamentos realizados quem era o "patrão" de ALESSANDRO, ou seja, o "dono" do ponto de venda em que ele era "gerente" (Biqueira da Nove), mas foi possível extrair que ele atuava em associação com MAILON, gerente do ponto de venda de drogas vizinho, sendo que o vínculo associativo para o tráfico de drogas entre eles pode ser depreendido da cooperação com que gerenciavam suas "biqueiras", dado o auxílio que um prestava ao outro na atividade ilícita, demonstrando a estabilidade, permanência e organização da associação.

ALESSANDRO foi preso em abril deste ano de 2021 por envolvimento com o tráfico em outro ponto de venda de drogas (Vila Maria), todavia restou certo pelo acima indicado que, à época dos fatos em apuração ele tinha função de gerente na

"Biqueira da Nove", no bairro Cristo Redentor."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

A preliminar de coisa julgada já foi afastada às fls. 611/613.
O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O topo do art. 35 desta lei dispõe:

Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei.

O tipo objetivo do topo do art. 33 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública (finalidade da proteção penal).
Já o tipo objetivo do topo do art. 35 pune a associação para o tráfico (prescindindo, portanto, da concretização do tráfico), ao passo que o tipo subjetivo consiste no dolo específico de se associar, de forma permanente ou estável, para praticar tais crimes. Embora a estabilidade ou permanência do pacto, em nossa interpretação, não sejam requisitos legais em virtude da expressão "reiteradamente ou não", as decisões dos tribunais tem se consolidado neste sentido (interpretando o art. 35 a partir do tipo da associação criminosa). O objeto material e jurídico é a paz pública.

A testemunha de acusação Delegado de Polícia Eduardo Henrique Palmeira Campos, em juízo, disse que o inquérito policial teve início a partir da prisão do MARLON PESSOTTO, preso no bairro Cristo Redentor, praticando a traficância que foi flagrada pela Polícia Militar; foi elaborado o auto em flagrante e ele confessou que estava praticando a traficância; na ocasião ele estava com o celular; é um velho conhecido pelos meios policiais, pois tem muito antecedentes por tráfico de entorpecentes na prática do ato infracional; o celular foi apreendido e submetido à perícia que mostrou que o MARLON estava em uma situação gerencial naquele local e se reportava diretamente ao JEFERSON, de vulgo "Gordão"; constatou uma outra figura que é o ALESSANDRO CRISTIANO, vulgo "Monstro", que inclusive já estava preso também pela prática de outro tráfico associado a outras pessoas; por meio da análise elaborada pelo policial civil Brizano; mostrou que a traficância era exercida pelo JEFERSON "Gordão" que é uma pessoa conhecida pela polícia, pois já foi flagrado no bairro que era o ponto conhecido como "Mombuca" e era visto sentado lá observando enquanto algumas pessoas vendiam para ele; nos diálogos ficou demonstrado que o MARLON conversava com o Alessandro e se intitulava gerente de um outro ponto de vendas lá no bairro Cristo Redentor; o MARLON trabalhava na biqueira se reportando ao JEFERSON que era o patrão e era próximo a outro ponto de venda em que trabalhava o Alessandro.

A testemunha de acusação, o policial civil Brizano A. Silva, em juízo, disse que na ocasião o MARLON HENRIQUE foi pego pela Polícia Militar; foi apreendido o celular dele que foi objeto de análise, onde extraiu o conteúdo; nas conversas entre o MARLON e uma pessoa identificada como "Primo", que posteriormente foi visto que seria o JEFERSON; são conversas relacionadas ao tráfico de drogas nas quais

JEFERSON fala sobre quando estiver acabando a droga avisar; em outra conversa ele dá "uma dura" em um indivíduo que não foi trabalhar no dia e reporta ao MARLON que tinha função de gerente ali no ponto de venda; e nas conversas no celular do MARLON tinha conversas com o nome Cristiane, mas tinha foto do Alessandro; eles conversavam entre os gerentes da biqueiras; teve uma situação de um pedindo ajuda para o outro; quando saiu a prisão do JEFERSON e do Alessandro, ele já havia sido preso em outro processo; o MARLON estava identificado como "Primo", e em vários momentos ele citou o JEFERSON "Gordão"; tinha a foto do ALESSANDRO no contato e a voz dele é fácil de identificação; é uma voz rouca forte; Alessandro era subordinado a uma outra pessoa que era o dono da "biqueira da Nove" que é uma biqueira próxima; MARLON era gerente e ALESSANDRO era gerente na outra biqueira; eles tinham um nível de amizade em que eles conversavam sobre o ponto de vendas, procuravam fechar sempre no mesmo horário para que uma biqueira não tivesse mais lucro que a outra; sempre dialogavam quando chegava a polícia avisava a outra; em uma das conversa ALESSANDRO fala que foi pegar a droga com outra pessoa que acredito que seria o Zezinho do PCC e pede para o MARLON avisar o dono da biqueira que ele iria atrasar um pouco.

JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, em juízo, disse que considera-se inocente, pois não é dono da "biqueira dos Mombuca", lá realmente é conhecido como Mombuca devido ao seu pai que tem esse apelido; sobre a denúncia que tem fotos dele lá, relata que não sabia das coisas que aconteciam lá; como só é ele e sua irmã que tem criança pequena, ele quem cuidava de seu pai que era doente; quanto à afirmação da investigação de que ele é dono da biqueira e ela parou de funcionar com sua prisão esclareceu que depois de dois meses mais ou menos o seu pai veio a óbito por causa de falta de medicamento, ele teve uma parada de respiração, tinha vários problemas como pressão alta, não se alimentava direito e como cuidava dele sempre era visto lá; tem foto sua lá, mas a casa é do seu pai; tem uma biqueira ali mesmo, mas não sabe quem vende, não sabe de nada; não mexia com essas turmas; em relação às conversas com o Marlon, são conversas diversas, estava falando com ele e foi apresentado que ele pegou o celular e colocaram ele como traficante; em relação à mensagem que fala do "print" esclarece que apenas era para colocar crédito no celular do Marlon; conhece o Marlon de quando ia lá ver o pai dele e a casa da mãe dele é ali perto; via ele só de vista, com "boa tarde" e "bom dia"; porque sabia que ali era um ponto de entorpecente e não falava muito com ele por causa disso. MAILON HENRIQUE CANDIDO PRESUNTO, em declarações perante a autoridade policial, disse que "nesta data estava promovendo venda de droga no ponto de venda de droga existente na Esquina da Rua Joao Simão com Alfredo Antonini no Bairro Cristo Redentor, quando foi abordado por Policiais Militares, sendo encontrado em seu poder uma pochete com o entorpecente ora apreendido; que o local é conhecido como "biqueira da árvore", sendo que a droga apreendida lhe pertencia e eram destinadas a venda; que vende a unidade de entorpecente a R\$ 10,00 reais; que sobre os valores, eram provenientes da venda de drogas até aquele momento; que não sabe a quantidade exata de drogas e valores apreendidos; que não conhece os Policiais Militares que o prenderam; que já esteve internado na função casa." Em juízo disse que naquela época considera-se culpado sim; não conhece o Alessandro; confirma que a droga é sua mesmo; esclarece que não associou-se com ninguém em relação ao tráfico; está sendo acusado falsamente porque conversava com seu primo e não sabe o porquê está falando de tráfico pra ele que na época foi sozinho; Jeferson não tinha participação nenhuma, ia no quintal só pra ver o pai dele; só conversava de vista com ele e a conversa pelo WhatsApp era conversa paralela que não tinha nada a ver com droga.

ALESSANDRO CRISTIANO SILVA em juízo disse que prefere ficar calado e só vai responder se o advogado quiser que responda; não tem apelido, seus colegas costumam te chamar de Alessandro ou Alexandre; ninguém o chama por Cristiane ou Cristiano e não é culpado pelo crime que está sendo imputado.

As testemunhas de acusação foram os policiais civis envolvidos na investigação.

Quanto aos relatórios, as defesas não conseguiram impugnar os seus conteúdos, tampouco conseguiram demonstrar qualquer intenção espúria dos funcionários públicos, razão pela qual os relatórios merecem credibilidade em relação aos fatos expostos e embasados em evidências.

Em juízo, os policiais civis também acrescentaram informações do que ficam sabendo a respeito dos acusados nas investigações; embora tais elementos sejam deveras importantes na fase inicial da persecução penal e ajudem na compreensão do contexto das atividades de investigação, não podem ser usados como provas contra o réus somente por terem sido ditos em juízo; o adjetivo que o texto constitucional usa para qualificar a defesa é "ampla", o que não admite para desfazer a presunção de inocência o uso de elementos que, na prática, são impossíveis de serem impugnados em razão da falta de acesso à fonte primária.

Com a devida vênia às competentes razões defensivas (fls. 763/768, fls. 769/777 e fls. 778/780) e ministeriais (fls. 731/759), em meu sentir a ação penal é parcialmente procedente, pois a acusação se desincumbiu do seu ônus probatório em relação aos delitos associativos somente.

O relatório de investigação de fls. 19/237 demonstra claramente que Jeferson e Mailon se associaram para a prática do tráfico, sendo o primeiro "proprietário" do famoso ponto de venda e o último seu gerente.

A relação entre ambos transcende a simples coautoria. Jeferson (com codinome "Primo" na agenda) emite ordens e coordena as ações de Mailon. Para "Primo" muitas vezes são direcionados os nomes de Jeferson (fls. 89 e 104) ou a alcunha "Gordão" (fls. 114), permitindo a identificação do interlocutor (adicionado ao reconhecimento pela voz).

Os trechos que evidenciam essa relação são inúmeros, como a instrução e ordem de Jeferson de fls. 33, fls. 82 e ss., fls. 100 e as falas de Mailon a partir de fls. 51 dando satisfações e pedindo instruções a Jeferson. Além disso, em diálogo com Alessandro, este diz que Mailon é gerente tal como ele (fls. 150).

Entretanto, a imputação dos delitos cometidos por meio da associação não implica em responsabilidade imediata de todos os seus integrantes, devendo a acusação fazer a prova relativa a cada pessoa imputada. E com a devida vênia ao representante do Ministério Público, não houve prova da participação moral de Jeferson em relação aos fatos especificamente narrados na denúncia (referentes ao art. 33 da Lei 11.343/06).

De outro lado, a associação entre Alessandro e Jeferson foi igualmente provada, principalmente pelos diálogos gravados a partir de fls. 136. As passagens contidas as fls. 145, 147, 150 (Cristiano diz "Você é gerente também igual eu"), 152, 199, 208, 210, 222, 224, 228 dão conta de uma intensa, permanente e estável colaboração entre os réus para a realização da traficância entre pontos de venda notórios (circunstância provada nestes autos) e vizinhos nesta cidade (fls. 139).

Configurado, assim, os delitos de associação para o tráfico cuja pena em abstrato é "reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da

violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.

(...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a

pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência

dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. ALESSANDRO tem uma condenação que configura maus antecedentes (autos 0001180-76.2012.8.26.0472), razão pela qual faz-se um acréscimo de um ano e dois meses, além de 83 dias-multa.

Tem razão o representante do Ministério Público ao afirmar a especial gravidade dos delitos pelo fato de se relacionarem com um bairro de extrema vulnerabilidade social e principalmente por constituírem notórios pontos de venda de drogas, os quais a experiência nos mostra serem afamados inclusive fora da comarca. Em razão disso acresço a pena de todos os réus em um ano e seis meses, além de 106 dias-multa.

A pena-base de Alessandro fica em cinco anos e oito meses de reclusão, além de 889 dias-multa.

A de Jeferson fica em quatro anos e seis meses de reclusão, além de 806 dias-multa. Mesma pena para cada imputação contra Mailon.

Segunda etapa. Presente a atenuante da menoridade relativa (inciso II do art. 65 do Código Penal) para MAILON, reduzo as penas em 1/6 (um sexto), deixando-as em três anos e nove meses de reclusão, além de 671 dias-multa (cada uma).

JEFERSON é reincidente (autos 0003318-45.2014.8.26.0472), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em cinco anos e três meses de reclusão, além de 940 dias-multa.

ALESSANDRO é multirreincidente (0001180-76.2012.8.26.0472 e 0001819-55.2016.8.26.0472), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em seis de reclusão e 1.074 dias-multa.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

A pena de todos os acusados supera a faixa de quatro anos, com forte negativa das circunstâncias judiciais, o que indica como adequado o regime inicial fechado. Sem contar que Jeferson e Alessandro são reincidentes.

O montante de pena imposto a MAILON também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA à pena de reclusão, pelo prazo de cinco anos e três meses, em regime inicial fechado, bem como a 940 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no art. 35 da Lei 11.343/06; para CONDENAR mailon henrique candido presunto à pena de reclusão, pelo prazo de sete anos e seis meses, em regime inicial fechado, bem como a 1.342 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude de duas condutas típicas descritas no topo do artigo 35 da Lei 11.343/06, em concurso material; e para CONDENAR alessandro cristiano silva à pena de reclusão, pelo prazo de seis anos, em regime inicial fechado, bem como a 1.074 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 35 da Lei 11.343/06.

Também para ABSOLVER JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA da acusação de tráfico a ele imputada na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado Jeferson, as razões

da prisão cautelar (fls. 424/426) estão mantidas.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes. STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança no regime prisional.

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que foram nomeados advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. Todavia, por serem inservíveis e antieconômicos para a SENAD, determino a destruição ou doação dos seguintes bens: 01 Pochete; 01 telefone celular de cor azul.

Mantenho as razões de fls. 611/613 a respeito da restituição do numerário de R\$499,00, pois nada nesta instrução infirmou a posse dele por parte de JEFERSON.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 25 de fevereiro de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA